

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) · 개 선 요 구

제 목 하도급계약의 부당특약 점검 미흡

소 관 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

조 치 부 서 △△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

△△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다), 사내 절차서 「△△(★★)-절차-공사관리-003, 건설공사 하도급 관리」(이하 “절차서”라 한다)에 따라 수급인으로부터 받은 하도급계약 사항을 검토하여 하도급 승인 여부를 결정하고 그 결과를 수급인에게 통보하고 있다.

이와 관련하여 △△ 천연가스발전소 건설공사 등 7건의 도급계약에 대해 변압기 절연유 분석장치 설치 등 40건의 하도급계약을 승인하여 분업화를 통한 효율적인 발전소 건설 시공에 노력하고 있으며, 불법·불공정 하도급을 사전 통제하고 수평적이고 공정한 하도급계약이 이행되도록 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「건설산업기본법」 제38조(불공정행위의 금지) 제2항에 따르면 수급인은 하수급인에게 관계 법령 등을 위반하여 경제상 이익을 부당하게 제한하는 특약을 요구하지 않도록 규정하고 있으며, 제3항에 따르면 「공공기관 운영에 관한 법률」에서 정한 공공기관인 발주자는 수급인으로부터 통보받은 하도급계약에 부당특약이 있는 경우 그 사유를 분명하게 밝혀 수급인에게 하도급계약 등의 내용 변경을 요구하도록 규정하고 있다.

또한 「하도급법」 제3조의4(부당한 특약의 금지) 제1항에서 원사업자는 수급사업자¹³⁾의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 “부당특약”이라 한다)을 설정하지 않도록 규정하고 있으며, 제2항 제2호에서 원사업자가 부담하여야 할 민원 처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급 사업자에게 부담시키는 약정을 부당특약으로 규정하고, 같은 법 시행령 제6조의4(부당한 특약으로 보는 약정)에서 [표 25]와 같이 원사업자에게 부과된 의무를 수급 사업자에 전가하는 사항을 부당특약의 유형 중 하나로 정하고 있다.

[표 25] 「하도급법 시행령」에서 정한 부당특약 유형

관련 조항	부당특약 유형
제6조의4	1. 아래의 비용이나 책임을 수급 사업자에게 부담시키는 약정 가. 원사업자의 의무 사항인 인·허가, 환경관리 또는 품질관리 등과 관련하여 발생하는 비용 나. 발주자 및 원사업자가 설계나 작업 내용을 변경함에 따라 발생하는 비용 다. 원사업자의 지시에 따른 재작업, 추가 작업 또는 보수작업으로 인해 발생하는 비용 라. 원사업자가 부담하여야 할 하자담보책임 또는 손해배상책임
	2. 원사업자와 수급 사업자가 예측할 수 없는 사항을 수급 사업자에 책임을 부담시키는 약정
	3. 간접비의 인정 범위를 일률적으로 제한하는 약정
	4. 계약기간에 하도급 대금 조정 권리를 제한하는 약정
	5. 기타 수급 사업자의 권리·이익을 부당하게 제한 또는 박탈하는 약정(공정거래위원회 부당특약 고시)

자료 : 「하도급법 시행령」 제6조의4 내용 재구성

13) 「건설산업기본법」에서 하도급계약 대상자를 발주자, 수급인, 하수급인으로 지칭하고 있으며, 「하도급법」에서는 「건설산업기본법」의 수급인을 원사업자, 하수급인을 수급 사업자로 지칭하고 있다.

그리고 「하도급법 시행령」 제6조의4 제5항과 관련하여 공정거래위원회의 「부당특약 고시」 Ⅱ. 부당특약의 유형 제4항 다 목에서 원사업자의 손해배상 책임을 관계 법령, 표준 하도급계약서 등의 기준에 비해 과도하게 감하거나 수급 사업자의 손해배상책임, 하자담보책임을 과도하게 가중하여 정한 약정을 부당특약으로 규정하고 있다.

한편 공정거래위원회 의결서(의결 제2024-283호, 2024. 8. 5.)에서는 발주자와의 도급계약 대비 약 2~3배 높은 지체상금률을 적용한 하도급계약에 대해 수급 사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 행위로 간주하여 「하도급법」 제3조의4 제1항 위반에 따른 경고 처분을 내린 사례가 있다.

이와 관련하여 절차서에서는 하도급 승인·평가·대금 지급 확인 등의 절차를 규정하고 있는데 “7.1.2 하도급 통지대상 공사”에서 주관부서와 시공부서는 하도급업체 법적요건심사표¹⁴⁾의 평가기준에 따라 계약상대자가 제출한 하도급계약 통보서를 심사하도록 규정하고 있으며, “7.1.3 하도급 승인대상 공사¹⁵⁾”에서는 법적요건심사와 더불어 하도급업체의 시공능력 평가 및 안전·품질 관리능력을 추가로 심사하도록 규정하고 있고, 이와 관련된 법적요건심사표의 평가기준에는 하도급계약의 부당특약 해당 여부를 점검하는 항목도 포함되어 있다.

따라서 공사주관부서는 계약상대자로부터 하도급계약의 통지 또는 승인을 요청받는 경우 절차서의 법적요건심사표의 평가기준에 따라 하도급계약 내용의

14) 「건설산업기본법」 및 「하도급법」에서 규정하고 있는 하도급업체의 공사수행 자격요건, 하도급 계약조건, 대금 지급, 분리 시공의 타당성, 안전사고 발생 이력, 부당특약 유·무에 대한 항목이 포함되어 있다.

15) 「건설산업기본법 시행령」 제34조 제1항에서 ① 하도급 계약금액이 도급금액 중 하도급 부분에 상당하는 금액의 100분의 82에 미달하거나, ② 하도급 계약금액이 하도급 부분에 대한 발주자의 예정가격의 100분의 64에 미달하는 경우를 저가 하도급으로 간주하고 있으며, 저가 하도급의 경우 하도급 승인 대상 공사에 해당하고, 저가 하도급에 해당하지 않는 경우 하도급 통지 대상 공사에 해당한다.

적정성과 부당특약 여부 등을 면밀하게 점검하고, 계약 내용이 적정하지 않거나 부당특약이 있는 경우 계약상대자에게 시정 요구를 함으로써 관련 법령을 준수하고 공정한 하도급계약이 이행되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△△△본부 ◆◆◆◆부는 “△△ 천연가스발전소 전력용변압기 기자재 구매” 등 2건에 대한 하도급계약의 법적요건심사를 진행하면서 [표 26]과 같이 하도급계약의 지체상금률¹⁶⁾, 하자보수보증금률이 도급계약에 적용받는 비율과 비교하여 약 2.5~4배 과도하게 부과되는 부당특약이 포함되어 있음에도 이를 정확히 확인하지 않은 채 적정한 것으로 심사를 진행하였다.

[표 26] 하도급계약의 지체상금률 및 하자보수보증금률 과다 부과 현황

도급 내역				하도급 내역				
계약명	수급인	지체 상금률	하자보수 보증금률	계약일자	하수급인	공사범위	지체 상금률	하자보수 보증금률
△△ 천연가스발전소 전력용변압기 기자재 구매	HD현대일렉트릭	0.075%	3%	2024. 09.04.	케이엠 데이터	절연유분석 장치 설치	0.2%	10%
△△ 천연가스발전소 154kV 가스절연 개폐 설비 기자재 구매	일진전기	0.075%	3%	2023. 11.23.	한빛 이디에스	GIS용 예방진단 시스템 설치	0.3%	10%

자료: 수감부서 제출자료 재구성

그리고 “△△ 천연가스발전소 전력용변압기 기자재 구매”의 하도급계약서

16) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1686 판결에 따르면 지체상금에 관한 약정은 수급인이 그와 같은 일의 완성을 지체하는 손해배상액의 예정이라고 판시한 바 있다.

제10조(안전관리 및 재해보상)에는 기타 모든 사고 등(수급인 및 하수급인의 직원, 행인, 제3자의 인사상 및 재산상 손해 포함)이 발생하는 경우 이에 대하여 하수급인이 민·형사상 일체 책임을 지도록 명시되어 있으며, “△△ 천연가스발전소 154kV 가스절연 개폐 설비 기자재 구매”에 대한 하도급계약서 제14조(산업재해 예방 및 안전관리 의무 준수) 다 항에는 계약 물품의 제작, 설치 및 시운전 과정에서 발생하는 산업재해 및 민·형사상의 모든 책임은 하수급인이 지도록 명시되어 있는 등 「하도급법」 제3조의4 제2항 2호에 해당하는 부당특약이 포함되어 있음에도 △△△△본부 ◆◆◆◆부는 해당 하도급계약의 법적요건심사 시 ‘적정’으로 평가를 진행하였다.

이와 관련하여 특약의 위법성은 수급인과 하수급인의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정하는 행위 그 자체로 성립되며, 부당특약 조항의 실현 유무나 부당특약에 따른 비용 전가 가능성 유무는 위법성 성립 여부에 영향을 미치지 않는 점¹⁷⁾을 고려할 때 위의 사항은 명백히 「하도급법」 제3조의4 제1항을 위배하는 사항이며, 공사주관부서에서 하도급계약의 부당특약에 관한 유형을 정확히 인지하지 못한 부분과 법적요건심사 업무를 소홀히 한 부분에서 비롯된 사항이므로 이에 대한 향후 재발방지 대책 마련이 필요하다.

관계기관 의견 및 검토결과

△△△△본부 ★★★★★실 ◆◆◆◆부는 △△ 천연가스발전소 건설공사 기간에 다수의 하도급계약 건을 심사하면서 일부 부당특약 사항을 검토하지 못한 부분을 인정하였으며, 향후 위와 같은 사항이 재발하지 않도록 하도급 관리를 철

17) 서울고등법원 2016. 12. 21. 선고 2015누2040, 서울고등법원 2017. 3. 30. 선고 2016누37753 판결 참조

저히 이행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 하도급계약의 법적요건심사 시 부당특약에 대한 점검이 적정하게 이행되도록 부당특약 유형을 구체적으로 절차서에 명시하여 개정하고, (개선) ② 하도급 계약조건에 부당특약이 포함되어 있음에도 승인하는 일이 없도록 검토 업무를 철저히 하시고 관련 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)